

1500488-42.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... com a detenção. A família não é envolvida com o tráfico. Nunca o viu com o adolescente. Conhece ele da lanchonete. O acusado mora ali perto. Só sabia que ele trabalhava no shopping, não sabe o horário. Já foi na casa do acusado, por perto não tem ponto de tráfico. Sabe que o tráfico ocorre no Ouro Branco. Não sabe se o imputado faz uso de entorpecentes, nunca viu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500488-42.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500488-42.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2302435/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21240586 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2766/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2302435 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2766/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO ALVES DOS SANTOS BRITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

VICTOR HUGO ALVES DOS SANTOS BRITO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, na forma do art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em 06 de novembro de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Jorge Vicente, 184, Jardim Ouro Branco, neste município e comarca, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente infrator Kayque Gabriel dos Santos, traziam consigo, para fins de tráfico, 109 (cento e nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 189g (cento e oitenta e nove gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado e o adolescente, agindo em concurso, traziam consigo as sobreditas substâncias para fins de comercialização.

Ocorre que guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local, já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o denunciado e o adolescente em uma área verde, sendo que o indiciado segurava uma sacola nas mãos.

No entanto, ao perceberem a presença da viatura, VICTOR dispensou a sacola ao solo e, juntamente com o adolescente, tentaram evadir-se de local, mas ambos foram detidos.

Na ocasião, os policiais localizaram a sacola dispensada pelo denunciado e, em seu interior, encontraram 109 (cento e nove) porções de cocaína, que seriam comercializadas por eles. Na posse do adolescente, por sua vez, foi encontrada a quantia de R\$44,00 (quarenta e quatro reais), proveniente do narcotráfico.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou o tráfico de drogas.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 118/120).

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 121/122).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defesa (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, anoto que o Julgador não está obrigado a determinar a realização do exame de dependência toxicológico se outros elementos de convicção vêm a justificar sua dispensa, como a existência de provas que apontam para a prática do crime de tráfico de entorpecentes e a clareza de raciocínio do acusado no interrogatório judicial.

O simples fato do réu ter alegado, quando de seu interrogatório judicial, ser usuário de drogas não impõe a obrigatoriedade de realização do exame referido (cf. STJ, HC 148.585/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 11/05/2011; RHC 15.788/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 02/05/2006, p. 388).

A alegação de dependência química é apta à instauração do incidente de insanidade, desde que instruída com elementos que indiquem a perturbação da saúde mental do acusado, o que de longe não é o caso dos autos (cf. STJ, REsp 97.071/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 450).

Segundo Hélio Tornaghi, o verbo ordenará, empregado no artigo 149 do Código de Processo Penal, não pode levar o intérprete a concluir que o juiz tem a obrigação de atender sempre ao requerimento de exame pericial. Lembra o ilustre penalista que o artigo 184 do mesmo diploma legal que, com exceção do exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a realização de perícia: "quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Se o juiz verifica que o pedido é meramente protelatório ou tumultuário, cabe-lhe policiar o processo e negar a perícia. Do contrário, não

seria um requerimento, mas uma imposição... Seria uma incoerência que o juiz pudesse repelir o laudo (CPP, art. 182) e não pudesse negar o exame" (TORNAGHI. Hélio. Curso de Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1).

Então, não há que se falar em exame de dependência no caso em tela.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 31/33 e 145/147), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que faz apenas uma semana que vende entorpecentes. A droga encontrada pelos policiais não era sua, mas do adolescente que estava em sua companhia. Sabia que o menor estava traficando. É usuário de drogas e estava no lugar e hora errada (fls. 10).

Em Juízo, o réu disse que tem 18 anos. Trabalhava no shopping como auxiliar de cozinha. É apenas usuário. Foi buscar drogas. Comprava entorpecentes com o menor. Foi o adolescente que dispensou a sacola. Saíram correndo. Tinha em seu poder quarenta e quatro reais em dinheiro. Não deu tempo de adquirir a droga. Os guardas apareceram de repente. Com medo correu. Foram abordados numa rua sem saída. Não falou aos guardas que vendia drogas. O local da prisão é dez minutos da sua casa. É uma biqueira. Costumava frequentar aquele local. É apenas um usuário. No dia iria comprar quatro pinos de cocaína. Cada pino custa dez reais. Não conhecia o adolescente. Já conhecia os guardas de outras abordagens por ser usuário. Nunca teve problemas com a justiça. Trabalhava como chapeiro. Era usuário de cocaína, não usava todo dia. No máximo usava cinco pinos. Tem folga uma vez por semana. De folga usava cinco pinos. Ganha mil e duzentos reais por mês. Gastava com drogas e ajudava sua mãe no aluguel. Gastava cento e cinquenta reais com entorpecentes quando estava de folga. Nunca usou droga com Jean. Está preso há seis meses. Não usou drogas durante a prisão, não passou mal quando foi preso. Não é dependente. A sacola em poder do adolescente era transparente. O menor apanhou dos guardas, ele deveria falar que a droga era dele. Tanto ele como o adolescente apanharam. As agressões não forma graves (mídia).

Sua versão judicial não convence e cede ante o conjunto probatório colhido.

Vejamos o teor da prova oral.

O guarda civil municipal Edison Dias de Souza contou que fazia patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância. Viram duas pessoas numa área verde. Ao ver a viatura, o acusado dispensou uma sacola plástica e saiu correndo, assim como o adolescente fugiu. Saíram no encalço e conseguiram alcança-los. Encontraram quarenta e quatro reais com o adolescente. Com o réu nada foi localizado. Na sacola dispensada havia 109 pinos de cocaína. Indagados, eles confirmaram a prática do tráfico. Eles foram vistos juntos antes da prisão. Quem dispensou a sacola foi o réu. Eles confirmaram que iriam vender os entorpecentes encontrados, a venda seria por dez reais cada pino. O local é muito conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas. O adolescente já era conhecido da polícia. O réu também era conhecido da guarda civil municipal. Já havia abordado o réu naquelas imediações, mas nunca encontrou entorpecentes e dinheiro nas outras oportunidades. O adolescente foi junto com a mãe dele no plantão policial e confirmou a venda de drogas. Não tiveram que empregar força física, só fizeram uso de algemas porque o

réu tentou fugir. Não viram qualquer usuário no local. Os fatos ocorreram no período da tarde (mídia).

O guarda civil municipal Osvaldo Moreira Junior contou que realizava patrulhamento de rotina. Em local já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, eles avistaram o acusado e o adolescente juntos em uma área verde. É habitual naquela região duas pessoas venderem drogas em conjunto, a movimentação é intensa. O acusado segurava uma sacola plástica, mas ao perceber a presença da viatura houve dispensa da sacola, jogando-a no chão. Em seguida, ambos saíram correndo pela via pública. Foram no encalço dos dois suspeitos e obtiveram êxito em abordá-los. Realizada busca pessoal, na posse do adolescente, dentro de sua bermuda, foi encontrada a quantia de quarenta e quatro reais em dinheiro. Na posse do denunciado nada foi encontrado, contudo, na sacola dispensada localizaram 109 pinos contendo cocaína. Indagados, o adolescente e o denunciado confessaram a prática do tráfico de drogas naquela área verde. Antes de serem abordados eles estavam vendendo o entorpecente a dez reais cada pino. Deram voz de prisão ao imputável e realizaram a apreensão do adolescente. O réu tinha uma sacola na mão e ele a dispensou ao ver a presença da guarda civil municipal. Sabe que na Delegacia o adolescente mudou a versão. Não sabe o que o réu falou ao delegado. Já havia abordado o denunciado em data anterior, assim como o adolescente naquele mesmo local da prisão. Não havia usuários no dia da detenção (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"APELAÇÃO. FURTOS SIMPLES. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. "REI" ENCONTRADAS EM PODER DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FURTOS CONSUMADOS. PENA INALTERADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAS SEM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Autorias e materialidades criminosas furtadoras devidamente comprovadas, sobretudo por meio da prova oral produzida em Juízo. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social.

Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). 3. Encontro das "rei furtiva" em poder do recorrente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017". (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

Foi ouvida uma testemunha de defesa.

A testemunha Jean Roberto da Silva contou que é amigo do réu. Conhece ele há nove anos. Não sabia do envolvimento dele com o tráfico. Nunca o viu em companhia de pessoas duvidosas. Sabia que ele trabalhava de cozinheiro no shopping. Ele não ostentava dinheiro e patrimônio. Ficou sabendo da prisão pelo padrasto do denunciado. Ficou surpreso com a detenção. A família não é envolvida com o tráfico. Nunca o viu com o adolescente. Conhece ele da lanchonete. O acusado mora ali perto. Só sabia que ele trabalhava no shopping, não sabe o horário. Já foi na casa do acusado, por perto não tem ponto de tráfico. Sabe que o tráfico ocorre no Ouro Branco. Não sabe se o imputado faz uso de entorpecentes, nunca viu nada, muito menos na casa dele. Não sabe se ele é dependente de drogas (mídia).

Pois bem.

De acordo com a prova oral colhida, guardas civis municipais realizavam patrulhamento pelo bairro e avistaram o réu e o adolescente em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Ao perceberem a presença da viatura, o acusado dispensou uma sacola ao solo, e juntamente com o adolescente, tentaram se evadir do local, sem sucesso, sendo detidos.

Os agentes públicos localizaram a sacola dispensada pelo réu e, em seu interior, encontraram 109 (cento e nove) porções de cocaína, que seriam comercializadas. Na posse do adolescente, por sua vez, foi encontrada a quantia de R\$44,00 (quarenta e quatro reais), proveniente do narcotráfico.

Indagados, eles confirmaram a prática do tráfico.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias da prisão em flagrante e o local da abordagem, com depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº

11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos guardas civis municipais quanto ao tráfico de drogas.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de

entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...). (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardínópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância. (...). (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Não foram arroladas testemunhas de defesa presenciais que pudessem corroborar a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, devendo prevalecer o relato dos guardas civis municipais que realizavam patrulhamento de rotina e o prenderam em flagrante delito.

Aliás, o adolescente Kayque, quando ouvido na delegacia, confirmou que a droga encontrada em sua posse era metade sua e metade do réu. O dinheiro encontrado em seu poder era proveniente da venda de entorpecentes. Vendia a dez reais cada pino de cocaína. Da venda da droga, ficava com a maior parte do dinheiro, uma porcentagem ficava como réu. Uma pessoa vai de moto taxi até o acusado e deixa a droga em um "mocó" (fls. 08).

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que permite concluir que, havendo algum suporte probante na fase judicial, a prova colhida no inquérito policial pode ser convocada para fundamentar a decisão condenatória, o que é o caso em tela.

Conforme já restou decidido:

“Havendo algum suporte probante na fase judicial, a prova colhida no inquérito policial pode ser convocada para fundamentar a decisão condenatória” (RT 621/290).

“A prova policial, inquisitória, só deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo, através de regular instrução” (RT 622/276).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da

droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são favoráveis ao réu, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem”.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu foi flagrado com grande quantidade de drogas (cento e nove porções de cocaína, com peso aproximado de 189 gramas), de delito que envolveu adolescente, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei.

De fato, a quantidade e a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (cf. STJ, AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, vez que o crime foi praticado na presença de Kayque Gabriel dos Santos, menor de idade, e o envolveu, conforme se vê do relato incriminador dos guardas municipais civis e do próprio adolescente ao ser ouvido em solo policial, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VICTOR HUGO ALVES DOS SANTOS BRITO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA